

1502617-41.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RODRIGO MARCOS DE ALMEIDA GERALDES

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/09/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294634/2021 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 21086845 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 3477/21/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2294634 - DEL.POL.FRANCISCO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502617-41.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502617-41.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294634/2021 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 21086845 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 3477/21/203 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO, 2294634 - DEL.POL.FRANCISCO MORATO

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu e Averiguado:

KAMILLY FARIAS DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO MARCOS DE ALMEIDA GERALDES

Vistos.

KAMILLY FARIAS DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 28 de outubro de 2021, por volta de 00h53, em ocasião de calamidade pública, nas imediações de estabelecimento de ensino, à Travessa Francisco Friso, altura do numeral 30, Jardim Nova Belém, Francisco Morato/SP, sem autorização e em desacordo

com determinação legal e regulamentar, trazia consigo: a) uma porção de maconha, com massa líquida total de aproximadamente 0,8g (oito decigramas); e b) três porções de cocaína, com massa líquida total de aproximadamente 169g (cento e sessenta e nove gramas).

Recebida a denúncia em 02 de dezembro de 2021 (fls. 84/85). A ré foi citada (fls. 107) e apresentou defesa prévia (fls. 130). Ratificação do recebimento da denúncia às fls. 133/134.

Na instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, a ré foi interrogada.

Após a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, em debates a Dra. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, pugnando pelo afastamento da causa redutora de pena e fixação de regime inicial fechado de cumprimento.

A Douta Defensora, por sua vez, requereu em memoriais a absolvição da ré por insuficiência de provas. Na hipótese de condenação, requereu o afastamento da causa de aumento de pena e a concessão dos benefícios cabíveis em vista da primariedade, que não justificariam a necessidade da custódia cautelar.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação merece ser julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE.

A materialidade delitiva restou comprovada diante do auto de exibição e apreensão (fls. 28), dos laudos de constatação preliminar (fls. 23/27) e definitivo (fls. 75/77) e, por fim, pela prova oral colhida em regular instrução.

A autoria também é certa, nos termos abaixo consignados.

Na fase extrajudicial, a ré Kamilly negou a prática dos fatos a si imputados (fls. 13), dizendo que parou no local apenas para comprar drogas para consumo próprio.

Interrogada, a ré mudou sua versão e admitiu a traficância. Disse que contatou Felipe e solicitou uma corrida de Jaraguá para Francisco Morato. No caminho, a interroganda pediu para Felipe pegar uma amiga dela, bem como Felipe igualmente deu carona a um conhecido dele. A seguir, após a amiga já ter desembarcado, houve a abordagem policial e a interroganda foi flagrada com os entorpecentes que pegou no Jaraguá e levaria para um contato em Francisco Morato. Disse, ainda, ter dois filhos, com dois e um ano de idade cada.

A assunção de autoria foi confirmada pelos demais elementos constantes dos autos. Senão vejamos.

O policial militar Elton relatou em juízo que estava em patrulhamento no local, o qual teria sido objeto de denúncia de tráfico. Em dado momento, avistou um veículo com dois homens e uma mulher. Eles foram abordados e com a mulher, a ora ré, encontraram um invólucro com cocaína na cintura, tendo ela mesma indicado outro na bolsa dela. Indagada, a ré admitiu que estava naquele momento abastecendo a "biqueira", bem como adicionou que os outros dois eram apenas do aplicativo "99" e não tinham nada a ver com o ilícito. Disse, ainda, que a ré ofereceu dinheiro para não ser presa. Não conhecia a ré. Reconheceu-a em juízo. Declarou que o local da abordagem é atrás de uma escola.

A seguir, o também policial Paulo Henrique descreveu a dinâmica dos fatos de forma

similar. Acrescentou que o entorpecente encontrado era basicamente cocaína em pasta base e que, indagada sobre organização criminosa, a ré disse que o marido dela estava preso e fazia parte de facção.

A narrativa dos fatos tecida pelos policiais em juízo não difere daquela constante de suas oitivas na fase policial.

Não há razão para desqualificar a prova policial, pois não há qualquer dado que afaste a natural credibilidade de que gozam tais testemunhas. São agentes do Estado, razão pela qual seus depoimentos devem ser avaliados sob a perspectiva da presunção de credibilidade, a menos que infirmados por outros elementos de convicção. Na espécie, a narrativa tecida por ambos é coesa, coerente, uniforme e detalhada. É o suficiente para lhes conferir importante valor probatório. No mesmo sentido, converge a lição diária de nossos tribunais:

Prova criminal - Testemunhal - Tráfico de entorpecentes - Depoimentos de policiais que efetuaram a apreensão - Credibilidade - Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador. (ACR 147980, Rel: Jarbas Mazzoni).

"o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF - 1ª Turma - HC 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

Por fim, pronunciou-se em juízo a testemunha Felipe. Disse que trabalhava como motorista de aplicativo e que, no dia, pegou a ré em Jaraguá e a deixaria em Francisco Morato. No caminho, a ré pegou uma amiga, a qual foi deixada em outro local antes que ocorresse a abordagem. Quanto a isso, afirma que policiais pararam o veículo e com a ré foram encontrados os entorpecentes apreendidos. Já tinha feito corridas para a ré antes, mas não tinha amizade com ela. Sabia que o local era próximo a um ponto de drogas, mas desconhecia o conteúdo do que a ré trazia consigo.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos, a ré não trouxe aos autos prova hábil a comprovar que os fatos não se deram da forma narrada na denúncia, ônus que lhe incumbia por força do art. 156 do Código de Processo Penal.

O crime de tráfico ilícito de drogas é infração que se integra de várias fases sucessivas, articuladas uma na outra desde a sua produção até a sua entrega a consumo, ainda que de forma gratuita. A quantidade de droga apreendida era relevante e se mostra suficiente, dentro do contexto probatório, para colocar em risco a saúde pública e a segurança da comunidade.

Por fim, vale consignar que o decreto condenatório não se ampara exclusivamente nos depoimentos colhidos em sede administrativa, e sim em todo o contexto probatório, corroborando a prova produzida em juízo a sucessão de fatos tal como foram apurados e narrados em sede policial, todos coesos no mesmo sentido.

Dosimetria da pena

Passo a dosar a pena, de acordo com o critério trifásico que informa o Código Penal.

Na primeira fase, levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no piso legal: em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, à razão mínima em face da situação econômica do acusado.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas. A atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal (súm. 231/STJ).

Na terceira fase, diminuo a pena pela metade, posto que a ré é primária (art. 33, §4.º), não ostenta antecedentes criminais e não ficou demonstrado de forma cabal que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa (art. 33, §4.º). A lei não estabelece parâmetro para a redução, logo razoável considerar para tanto a quantidade como a variedade de drogas apreendidas – no caso em tela está-se a falar de quantidade relevante de cocaína (aproximadamente 170 gramas).

Todavia, a prova oral não se mostra suficiente por si só para comprovar que a atividade ilícita era realizada próxima a uma escola, motivo pelo qual não se vislumbra razão para a aplicação no caso em tela da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006.

Isso porque não há comprovação de que a ré tivesse ciência da proximidade de uma escola ou, mais, que se valesse de tal circunstância para assim amealhar possíveis compradores para os entorpecentes, até mesmo porque os fatos se deram de madrugada.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos da recentíssima decisão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo (Tema 600), que cancelou a súmula 512 daquela Corte e acompanhou o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 118533.

Ainda que se tenha excluído a hediondez para os casos de tráfico privilegiado, ou seja, aquelas hipótese em que se aplica o §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, inviável neste caso específico a substituição por pena alternativa porque é incompatível a benesse prevista precipuamente para crimes de pequeno potencial ofensivo, não se mostrando suficiente para as finalidades da sanção penal para casos em que a quantidade de entorpecentes era relevante como o é na espécie (art. 44, inciso III, do Código Penal).

Inaplicável a suspensão condicional da pena, diante das circunstâncias do caso concreto, as quais apontam que tal medida não é socialmente recomendável.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO KAMILLY FARIAS DOS SANTOS à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a pagar multa de 250 dias-multa, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/06.

Em que pese a alteração legislativa levada a efeito com a publicação da Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, em especial da redação do seu art. 1º e 2º, deixo de aplicá-la em sua integralidade.

Ora, trata-se de dispositivos manifestamente inconstitucionais, posto que violam os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia.

O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da

Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

Na primeira, caberá à lei fixar as penas que serão aplicadas para cada tipo penal. A quantidade da pena deve guardar proporção com a importância do bem jurídico tutelado e a gravidade da ofensa. Por isso, cada tipo penal prevê quantidade mínima e máxima de pena e, em alguns casos, espécies distintas de sanções penais, que podem ser aplicadas, dependendo do caso, alternativa ou cumulativamente.

Na etapa judiciária, caberá ao juiz, à vista da infração cometida, escolher a pena que será aplicada dentre as cominadas no tipo penal, dosar a sua quantidade entre o mínimo e máximo previsto, fazer inserir causas que possam aumentar ou diminuir a reprimenda, fixar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como analisar possível substituição por pena mais branda.

Cuida-se de critério em que o julgador possui discricionariedade regrada. Isso porque, embora tenha liberdade de escolha quanto à pena que irá aplicar, bem como sua quantidade, deve obediência a regras previstas no Código Penal.

Por fim, após a aplicação da pena, há necessidade de sua execução. As diretrizes quanto à execução da pena estão previstas principalmente no Código Penal e na Lei das Execuções Penais.

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão".

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória,

deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF).

Tendo em vista que a ré responde a todo processo custodiada e inalteradas as circunstâncias, deve responder a eventual recurso nesta condição, mas mantida a prisão domiciliar nos termos da decisão de fls. 47/49.

Declaro o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, tendo em vista a comprovação de que provém do tráfico.

Após trânsito em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral. Oficie-se, acaso tal já não tenha sido feito, para incineração total ou parcial das drogas como acima determinado e providencie-se o necessário quando ao perdimento do dinheiro, comunicando-se ao SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06). Após, archive-se.

P.I.C.

Francisco Morato, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA